

1500673-35.2022.8.26.0587

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... a ré, mas a mesma já respondeu por tráfico de drogas.

O policial civil Bruno Cardoso da Silva e Sousa, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que a ocorrência gerou em decorrência de diligências na Costa Norte para combater o tráfico de drogas. Foi identificado um possível ponto de vendas dentro de uma residência. Foram feitas atividades prévias de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, ., Varadouro - CEP 11600-000, Fone: (12) 3892-3111, Sao Sebastiao-SP - E-mail: saosebacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital:

1500673-35.2022.8.26.0587 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRÍCIA DA CUNHA BARNABÉ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucia Fernandes Paiva

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 56/57, no dia no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 09:00 horas, na Rua Recanto dos Atobas, nº 242, no bairro Praia da Enseada, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, FABRÍCIA DA CUNHA BARNABÉ, qualificada à fl. 06, trazia consigo para fins de tráfico de drogas, 104 porções de cocaína, pesando aproximadamente 94,88 gramas; 66 porções de maconha, pesando aproximadamente 99,52 gramas; 46 porções de crack, pesando aproximadamente 38,08 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 19/20, fotografia de fls. 15/18 e auto de exibição e apreensão de substância entorpecente de fls. 13/14.

Em razão destes fatos, a ré FABRÍCIA DA CUNHA BARNABÉ, qualificada à fl. 06, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 91/93). Sobreveio resposta à acusação (fls. 99/110), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 126/127).

Houve a realização de audiência de instrução (fls. 248/253), com a oitiva de três testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório da ré.

Em audiência de instrução, foi requerido a liberdade provisória da ré considerando que ausente o periculum in mora e não mais subsistirem os motivos ensejadores da decretação de sua custódia cautelar, o que foi deferido pelo Juízo.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia, em razão do conjunto probatório, em especial o depoimento dos policiais civis, ouvidos em juízo.

Ao passo que a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal considerando primariedade da acusada; o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase de dosimetria; requereu na terceira fase a aplicação da atenuante do privilégio, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena observando o quantum de pena fixada. Requereu, ainda, o direito da acusada recorrer em liberdade, a isenção da pena de multa e a aplicação da detração penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência (fls. 09/12), laudo de constatação (fl. 19/20), relatório policial (fls. 132), laudo químico toxicológico (fls. 233/236) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a ré.

O policial civil André Pittiôni Scarinci, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que, após observar que a "biqueira" da ré estava funcionando, efetuaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Com o auxílio da ré, acharam a cocaína e o crack na cozinha e a maconha dentro de um urso de polícia. Foi dada voz de prisão à ré, com apreensão de dinheiro, dois aparelhos celulares e os entorpecentes. Antes dos fatos, a ré figurava como alvo de um relatório de investigação preliminar que culminou em um mandado de busca e apreensão. Às reperguntas da Defesa disse foram feitas duas campanhas de cerca de 40 a 60 minutos a fim de constatar a atividade de traficância, antes da confecção do relatório preliminar e a solicitação do mandado de busca. Foi realizada uma campanha no dia dos fatos a fim de constatar se a residência da ré era ponto de drogas, o que foi constatado, culminando no cumprimento do mandado. Foi verificado usuários chegando no portão, entregando dinheiro. Não sabe precisar quando se iniciou a traficância. Não houve denúncias, mas diligências no local por sempre monitorarem o bairro. Próximo ao local de residência da ré, já existia outros pontos de drogas. Não sabe dizer se atualmente existem outras "biqueiras", mas já existiu várias. Não conhecia a ré, mas a mesma já respondeu por tráfico de drogas.

O policial civil Bruno Cardoso da Silva e Sousa, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que a ocorrência gerou em decorrência de diligências na Costa Norte para combater o tráfico de drogas. Foi identificado um possível ponto de vendas dentro de uma residência. Foram feitas atividades prévias de campanha, onde foi feito um relatório prévio e a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão. No dia dos fatos, houve a realização de outra campanha, sendo constatada a movimentação característica do tráfico. Houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, estando no imóvel a ré, dona do imóvel, junto com suas duas filhas. Questionada sobre a presença de ilícito, a mesma confessou a presença de drogas e indicou o local: cocaína e crack na cozinha e maconha dentro de um urso de pelúcia. Houve a apreensão de dois telefones celulares e dinheiro. Foi dada voz de prisão para a ré com o encaminhamento da mesma à delegacia. A ré já é conhecida dos meios policiais, tendo passagens anteriores por tráfico. Em 2019 ou 2020 o filho da ré já foi apreendido por tráfico de drogas. Em campanha preliminares, conseguiram identificar a ré pelas suas características, considerando que a mesma já era conhecida dos policiais civis. Às reperguntas da Defesa disse que descobriram o ponto de drogas por volta de um mês, um mês e meio antes da data dos fatos. Antes disso, não havia investigações, não tendo como afirmar se ali era ponto de drogas. Perto da casa da ré existiam outros pontos de drogas, sendo um em uma ponte onde não foi identificada movimentação na época. Observava a movimentação, mas não conseguia enxergar a entrega. Observava o usuário chegando, chamando no portão, entregando alguma coisa ao ser atendido e depois indo embora após receber algo. Não dava para ver a droga pois as porções eram pequenas.

A testemunha defensiva Felipe Ram Ses Olimpo Teixeira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que não tem detalhes sobre a prisão da ré.

Sabe informar que a acusada é mãe solteira, tem cinco filhos, sendo uma deficiente. Os pais dos filhos não eram presente, pelo pouco que sabe. Acredita que a ré passava dificuldades financeiras, uma vez que sempre se ajudaram dividindo cestas básicas na época em que eram vizinhos. Acredita que na rua da ré existiam "biqueiras" por conta de comentários, mas não sabe informar o local. Nunca viu movimentação de tráfico de drogas na casa da ré.

A testemunha defensiva Juçara Helena Maia, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que não acompanhou a prisão da ré. Sabe que a ré tem cinco filhos, sendo uma cadeirante e a caçula de 02 (dois) anos de idade. Sempre que a ré precisava de alguma coisa, como alimentos, ia em seu portão para pedir ajuda, mas nunca pediu dinheiro. Não sabe falar sobre o pai das crianças, pois a ré morava apenas com os filhos. Moravam a duas casas de distância, mas nada sabe falar sobre movimentação de usuários de drogas pois nunca fica na rua em decorrência de seu trabalho.

A ré Fabrícia Da Cunha Barnabé, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou parcialmente os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que as drogas foram encontradas em sua residência, mas não exercia a traficância. Um rapaz lhe pediu para guardar as drogas em residência, tendo aceitado pois estava com muitas dívidas. Não pode falar quem era o rapaz. Um dos pais de suas filhas esta presa, então realmente havia cartas de gente presa em sua residência. As anotações referentes ao tráfico foram realmente encontradas pelos policiais e estavam dentro de uma das sacolas. Às reperguntas do Ministério Público disse que a rua da sua casa é a rua da "biqueira", guardava a droga pois era próximo. Os usuários batiam sua porta para saber se as drogas estavam sendo vendidas. Não sabe o motivo pelo qual os policiais estavam mentindo, sendo que indicou onde estavam as drogas aos policiais. Disse que ia receber R\$ 500,00 pela guarda dos entorpecentes, tendo ciência que estava guardando produtos ilícitos. Às reperguntas da Defesa disse que tinha pego a droga um dia antes. Três meses atrás tinha feito o mesmo. Seu ex esposo a traiu e ela o mandou embora, então estava cheia de dívidas. Esta grávida de oito meses. Conhece os "meninos" e já teve relacionamento com um deles, que já tinha oferecido para ela guardar drogas uma vez. Sua casa era um ponto de guarda de drogas, uma espécie de um depósito, uma vez que os traficantes estavam tendo muita "perda" por causa da polícia. Quem batia na sua porta era o pessoal da "biqueira", eventualmente algum usuário passava para perguntar acerca dos traficantes. Entregava pequenas porções aos traficantes, conforme eles iam pedindo. O dinheiro apreendido era de sua filha deficiente, que faz e vende pulseiras. Tem cinco filhos: 26, 21, 17, 11 e 2 anos, estando grávida de oito meses. Sua filha mais velha tem paralisia cerebral, precisando de ajuda para tudo, inclusive para dar banhos, trocar as fraldas. Recebe um salário a título de LOAS: benefício de prestação continuada. Sua tia esta cuidando de suas filhas. Pois bem.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os mesmos tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente a ré, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Existe um nexu íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

A ré, em juízo, admitiu a posse dos entorpecentes (104 porções de cocaína, pesando aproximadamente 94,88 gramas; 66 porções de maconha, pesando aproximadamente 99,52 gramas; 46 porções de crack, pesando aproximadamente 38,08 gramas), afirmando que estava guardando em troca de pagamento.

As testemunhas defensivas nada falaram acerca dos fatos.

Ressalte-se que os policiais disseram que localizaram os entorpecentes por indicação da ré. Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSP Ap.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tem em depósito, caso dos presentes autos:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação da acusada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isente a ré de sanção.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, vez que a ré é portadora de bons antecedentes (fls. 58/60 e 61/62) e as circunstâncias do delito não desbordam do ordinário.

Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade e variedade de entorpecente apreendido (104 porções de cocaína, pesando aproximadamente 94,88 gramas; 66 porções de maconha, pesando aproximadamente 99,52 gramas; 46 porções de crack, pesando aproximadamente 38,08 gramas) na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que a ré é primária e tem a seu favor a

atenuante da confissão descrita no artigo 65, I, do Código Penal. Contudo, a pena já está no mínimo legal e não pode ficar aquém desse patamar nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade da acusada e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Diminuo a pena na fração mínima de 1/2 (metade), em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, com elevado potencial de causar dependência química aos seus usuários (STJ, AgRg no REsp 1.902.218, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.03.2021), resultando assim a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Como a ré é primária e sem antecedentes e como a pena não superou quatro anos e as circunstâncias judiciais não justificam punição maior, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da detenção (artigo 33, § 2º, 'c', Código Penal).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, dada a quantidade de pena global aplicada e a primariedade, sopesando-se ainda as circunstâncias em concreto já estampadas na fixação das penas, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado FABRÍCIA DA CUNHA BARNABÉ, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica da ré.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, porque nessa condição encontra-se atualmente para este processo, não havendo qualquer motivo para justificar sua segregação cautelar.

A ré não apresentou prova da origem lícita dos valores com ela apreendida, razão pela qual decreto sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal da ré, expeça-se o necessário quanto aos valores e às drogas.

Cumpra-se .

Condena a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA